

1500095-84.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... declarou que está preso por tráfico de drogas com sentença. Sobre os fatos disse que a acusação e foi saber que estava preso por tráfico de drogas somente quando chegou na Delegacia, pois acreditava que estava sendo preso por receptação da motocicleta, pois tinha acabado de sair da cadeia e não estava fazendo tráfico de drogas, sabia o que estava fazendo. Sobre o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500095-84.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-84.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN WILLIAM CAETANO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra KAUAN MARQUES TORRES, qualificado à fl.07, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e JONATHAN WILLIAM CAETANO DOS SANTOS, qualificado às fls. 22/23, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 01 a 25 de janeiro de 2022, uma avenida do bairro Humberto Salvado, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, KAUAN MARQUES TORRES, qualificado à fl.07, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a motocicleta Honda/CG 125 FAN, ano/modelo 2006, cor preta, placa DEP 3329 - Narandiba-SP, avaliada à fl. 52 em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante boletim de ocorrência de fls. 65/66 e auto de exibição e apreensão de fls. 50/51. 2. Consta, também, que no dia 25 de janeiro de 2022, por volta de 14h39min, na Rua Joaquim Moraes, n.º 89, Bairro Conjunto Habitacional Brasil Novo, nesta cidade e

comarca de Presidente Prudente, JONATHAN WILLIAM CAETANO DOS SANTOS, qualificado às fls. 22/23, trazia consigo para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 06 (seis) invólucros contendo aproximadamente 47,74g (quarenta e sete gramas e setenta e quatro decigramas) de cocaína na forma de crack, acondicionados em material plástico, consoante auto de exibição e apreensão (fl. 49), fotografias (fls. 58/59) e laudo pericial definitivo de fls. 127/128. Segundo apurado, consoante ocorrência policial de fls. 65/66, o ofendido Rafael Ferreira Medeiros estacionou a motocicleta acima descrita nas imediações do Hospital Regional local, de onde foi subtraída no dia 18 de janeiro do corrente ano por terceiro não identificado. Após, o denunciado KAUAN, entre os dias 18 e 25 de janeiro de 2022, adquiriu a motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa DEP 3329 - Narandiba-SP, mesmo ciente da sua origem espúria, posto que pagou pelo bem valor irrisório, estando ainda o veículo na posse de pessoa que não era de seu relacionamento e sem qualquer documento de procedência. Paralelamente, o denunciado JONATHAN havia há pouco deixado estabelecimento penal em que cumpria pena pela prática do tráfico de drogas e, novamente adquiriu substância entorpecente para posterior revenda. No dia dos fatos, KAUAN conduzia a referida motocicleta, figurando JONATHAN como caronista. Contudo, sem ciência daquele, JONATHAN trazia consigo seis invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack" com peso líquido aproximado de 47,74g (quarenta e sete gramas e setenta e quatro decigramas). No local indicado acima, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram os denunciados na referida motocicleta. Cientes do envolvimento de JONATHAN com o tráfico de drogas e da subtração do veículo automotor ocorrida há poucos dias, deliberaram abordá-los. KAUAN e JONATHAN ao avistarem a viatura policial empreenderam fuga, inicialmente valendo-se da motocicleta e, após, abandonaram o veículo e correram em direção a um matagal. No caminho JONATHAN dispensou o entorpecente, que foi prontamente recuperado pelos policiais. Considerando a apreensão do entorpecente em razoável quantidade e as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, está evidenciado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ilícita.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 172/176), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 180), o despacho de fls. 183/183, de 9 de março de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 295/296), pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 300/305), deve o réu ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, Código de Processo Penal, por absoluta ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que lhe seja aplicada a pena no mínimo legal, reconhecendo-se a menoridade relativa e a atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal. É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 49; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 55/57; pelo laudo químico toxicológico de fls. 127/129, atestando - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0036267)

Descrição: 06 (seis) invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de material sólido petrificado. Massa Bruta e/ou Quantidade: 54,67 grama(s) - cinquenta e quatro gramas e sessenta e sete centigramas. Massa Líquida: 47,74 grama(s) - quarenta e

sete gramas e setenta e quatro centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelas fotografias de fls. 58/59; pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 212/241; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a vítima Rafael Ferreira Medeiros, declarou que a subtração da moto foi quando estava trabalhando e ao retornar, após as 18 horas, percebeu que moto havia sido furtada e chamou a Polícia. Quando a moto foi encontrada, foi até a Delegacia e lhe restituí-la, passou por vistoria porque lhe disseram que estava sendo usada para tráfico de drogas.

O PM. Carlos Roberto Miron Junior, sob o crivo do contraditório declarou que o veículo era produto de furto e estava transitando na cidade. Pelo sistema Radar, que é o sistema de vigilância em vias públicas interligadas com a Secretaria de Segurança Pública acusava que ela estava transitando durante o dia. Por coincidência avistou a moto vindo de frente com a viatura e ao avistarem a viatura, encostaram a motocicleta e saíram correndo. Ao correr no meio do mato, Jonathan dispensou um saco azul que continha porções de crack. Visualizou quando Jonathan dispensou o saco com a droga, ele era o garupa e logo o piloto tomou-lhe a frente. Foi bem rápido a sua abordagem, logo que ele abandonou a droga e ambos foram pego na rua de baixo. Indagado sobre a droga, disse que não lhe pertencia. Não conhecia o réu antes dos fatos.

O PM. Matheus Rodrigo de Souza, sob o crivo do contraditório declarou que estavam se deslocando para uma ocorrência no Bairro Brasil Novo e se depararam com a motocicleta com dois indivíduos, e ao visualizarem a viatura, demonstraram atitude suspeita e se evadiram, e não conseguindo, deitaram a motocicleta na calçada e ingressaram num terreno baldio do mesmo bairro. O garupa que era o Jonathan dispensou uma sacola de mercado, azul, ao chão e correu. Seu parceiro correu atrás e passou o rádio para o copom passando a placa da motocicleta que constatou se tratar de produto de furto, e acionado o Águia, bem como outras viaturas, fizeram o cerca e conseguiram deter os suspeitos. Em busca pessoal encontraram R\$ 30,00 com o Jonathan.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

“PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))”.

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” - “Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas

que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))”

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ E Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

O réu Jonathan William Caetano dos Santos, em seu interrogatório declarou que está preso por tráfico de drogas com sentença. Sobre os fatos disse que a acusação e foi saber que estava preso por tráfico de drogas somente quando chegou na Delegacia, pois acreditava que estava sendo preso por receptação da motocicleta, pois tinha acabado de sair da cadeia e não estava fazendo tráfico de drogas, sabia o que estava fazendo. Sobre o saco plástico de cor azul não estava com ele, não dispensou e nem estava com dinheiro, a única coisa eu portava era seu celular. Correu um pouco e já se entregou e foi preso, mas afirma não estar com nenhuma droga.

Encerrando-se a instrução processual.

A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que esclarece de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelo réu, além disso, sua narrativa não conseguiu desmerecer a palavra coesa e harmônica dos Policiais Militares.

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (06 porções de crack pesando 49,24 gramas), bem como numerário (R\$ 30,00), além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga mas também do dinheiro na quantia de R\$ 30,00 (trinta reais).

Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 58/59, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a origem lícita do numerário apreendido em sua posse, o que faz crer que era fruto da traficância de drogas por ele exercida.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de

coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu, já que é evidente a sua condição de traficante, até porque há notícias nos autos de que já houve condenação por outros dois processos por crime idêntico, demonstrando sua personalidade voltada ao crime e é evidente que faz dele seu meio de subsistência.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos."

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado. No caso em apreço, o réu vinha trazendo consigo, transportando cerca de 47,74 gramas de crack em forma bruta, que certamente após fracionada, renderia muitas outras porções menores que seria destinada a venda a usuários.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

A isso tudo se alia o constatado pela perícia no celular apreendido de propriedade de Jonathan William (fls. 212/241), consta conta de e-mail vinculada -

jonathancaetano834@gmail.com, Número vinculado ao WhatsApp: +5518996420236, e inúmeras conversas direcionada a drogas, até mesmo com pessoa nominada como

"MinhaVida", possivelmente sua namorada, e o assunto de maior relevância é quando comentam sobre uma ação policial, onde entraram na casa da tia do réu e de maior interesse a conversa de folha 222 "...Tá atrás de uns cinco menino, que eles fica na pracinha, que eles fica pra lá e pra cá. Disse que eles vai pega um por um, que

vai voltar tudo pro fechado, se for de menor vai tudo pro lar. Fala pra eles desse jeito, avisa eles pra eles toma cuidado aí porque falo assim que vai voltar aqui em casa, pra sabe quem é esses menino. Então avisa aí pro Jhow, pro Jhow fica longe do Cleiber, pro Cleiber ficar longe do Marcus, todo mundo ficar longe de todo mundo aí ó. Porque se pega, vai leva eles... Eles tá muito na ativa, que eles tá vendo, o investigador tá pra lá e pra cá...), e outra de bastante interesse aos autos, segundo o apontado pelo Dr. Promotor de Justiça é o diálogo travado entre o réu e pessoa nominada como "Cunhada", onde o réu ensina como guardar a droga e não perdê-la, como segue: "Não, onti ele falou que não achou pra mim não, mano. Aí ele falou que hoje ia cedo lá pra vê se conseguia acha" e ela responde "tbm que esconde as coisa no escuro nem marcou onde colocou. Quando ele chega nós já vai"; "Entendeu? Eu falei pra ele, mano, quando for esconder esses baguio esconde perto de muro, tá ligado. O muro assim, cava um lugar perto do muro assim que vai saber na onde que tá, mano" e "Aí ele vai lá, ele quer esconder no meio, no meio do baguio. Por qualquer lado que se for, se for pelo Marco Antônio ou pelo lado do Jaro, vai aparecer os memo lugar memo, vai ser igualzinho, é tudo igualzinho lá." Observo que o celular pertence ao réu Jonathan William, e possui fotos de pessoas usando drogas, destas propriamente ditas, e que várias delas foram tiradas do próprio celular do réu, traziam em seu metadados, informações do aparelho que produziu a foto e a geolocalização de onde foi tirada a foto, portanto, evidencia com grande eloquência nos autos a participação do réu no comércio espúrio de drogas.

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de trazer consigo a droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória e nem que o réu concorreu para a prática do crime.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua folha de antecedentes criminais de fls. 70/73 e da Certidão Estadual de Distribuição de Processos de fls. 74/75, que respondeu a dois outros processo e foi condenado recentemente por crime de tráfico de drogas, pois, pouco tempo após cumprir a pena, veio a ser novamente processado por idêntico crime, demonstrando que seu comportamento não é merecedor de quaisquer benefícios, agravando sua situação, pois faz do crime de tráfico de drogas o seu meio de subsistência, ainda que não possa ser considerado reincidente.

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração as circunstancias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que lhes são desfavoráveis, todavia o processo servirá para anotação da sua reincidência, fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pagar a multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, ausentes agravantes, contudo, presente a atenuante genérica da menoridade relativa do réu, que possuía menos de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, conforme dispõe o artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Impende mencionar, que embora não lhe retire a primariedade, o apontamento de dois processos que o réu responde por tráfico de drogas, evidencia sua dedicação a atividades criminosas, não incidindo, na hipótese, a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Entretanto, impede ela a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, já que demonstrar que o réu se dedicava há algum tempo a prática do tráfico de drogas.

Aliás, convém mencionar que o referido artigo trata da figura do traficante "privilegiado", também chamado de "traficante menor" ou de "traficante eventual", na qual se estabelece a redução requerida pela d. Defesa do réu, desde que, preencha todos os requisitos, ou seja, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integral qualquer organização criminal, que são cumulativos, diga-se de passagem.

Nesse sentido é o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em recentíssima decisão colegiada:

"APELAÇÃO Tráfico de drogas Preliminar de ilicitude da prova - Violação de domicílio Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local Preliminar afastada Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar que o réu tinha em depósito as drogas apreendidas para fins de tráfico Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Condenação mantida Pena-base mantida Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação do acusado a atividades criminosas Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos diante do montante da pena imposta Alteração do regime de cumprimento de pena para o inicial fechado, compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (Apelação Criminal nº 1500101-28.2021.8.26.0583 - Voto nº 4583 - Presidente Prudente - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relatora Fátima Gomes - 31/8/2021 - v.u.).

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva" (AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) Grifo nosso.

Ainda:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (EResp 1431091/SP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2014/0015576-0, Relator Ministro FELIX FISCHER, j. 14/12/2016) (Informativo 596, STJ, 1º de março de 2017) Grifo nosso. Com efeito, diante do delito praticado pelo réu, a fixação de regime fechado é compatível com a gravidade do delito, mormente pela sua dedicação ao comércio espúrio de drogas, restando insuficiente para a reprovação e prevenção do crime a fixação de outro regime. Ademais, torna-se imperioso maior rigor punitivo, sendo

mister a fixação do regime inicial fechado.

Nem se alegue, igualmente, ofensa aos entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu JONATHAN WILLIAM CAETANO DOS SANTOS, RG: 64188767, CPF: 540.878.258-17, nascido em 12/11/2002, natural de Presidente Prudente - SP, filho de PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS e THAIS CAETANO, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado; e a pagar a multa de valor correspondente a 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ainda sobrevivem os motivos da decretação da prisão preventiva do réu nestes autos e tendo ele respondido a todo o processo preso, agora, imponho-lhe a obrigação de recolher-se à prisão para poder apelar desta sentença.

INCONTINENTE, comunique-se a sentença no presídio que o réu se encontrar.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Decreto a perda em favor da UNIÃO de todo o numerário apreendido nos autos, posto que oriundo do tráfico de drogas.

Determino a imediata destruição dos aparelhos celulares apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA